

1501058-82.2019.8.26.0394

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Nova Odessa

Foro: Foro de Nova Odessa

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Odessa

Foro de Nova Odessa

1ª Vara Judicial

Avenida João Pessoa, nº 1300, Nova Odessa-SP - cep 13380-094

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501058-82.2019.8.26.0394 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501058-82.2019.8.26.0394

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2323928/2019 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 8416971 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 3115/19/318 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 2323928 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 3115/19/318 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 2323928 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 3115/19/318 - DEL.POL.NOVA ODESSA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DE OLIVEIRA LEITE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Wellington de Oliveira Leite, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a autoria de crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/03, ao argumento de que na noite de 6 de novembro de 2019, na Avenida São Gonçalo, Praça - Santa Rita I, nesta cidade, o denunciado guardava e tinha em depósito 10 (dez) micro tubos de cocaína pesando cerca de 6 gramas e 6 (seis) porções de maconha pesando cerca de 17 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificado (fl. 95), o acusado ofereceu defesa prévia às fls. 97/98.

A denúncia foi recebida em 28 de abril de 2021(fls. 99/100).

Certificada a citação do réu à fl. 109.

Não configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, restou designada audiência para produção da prova oral.

Ao longo da instrução foram ouvidas testemunha(s), bem como interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação e pela fixação de pena no patamar mínimo legal (fls. 136/138).

A Defesa, por seu turno, suscitou a irregularidade da prisão, requereu a absolvição pela ausência de provas e, subsidiariamente, postulou por benefícios no tocante às penas (fls. 142/148).

É o relatório.

DECIDO.

De início, rechaço a tese de nulidade da prisão em flagrante do réu.

Isso porque foi detido em plena via pública, sendo certo que qualquer do povo poderia ter promovido sua prisão em flagrante (art. 301 do Código de Processo Penal), de forma que inexistente irregularidade na realização do ato pela Guarda Municipal, em que pese não constar no rol de suas atribuições constitucionais. Nesse sentido é o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. MEIOS ILÍCITOS. OBTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. INTELIGÊNCIA. 1. Qualquer um do povo pode prender quem se encontre em flagrante delito, não obstante a atribuição da Guarda Municipal atribuída pela Constituição (ex vi, art. 144, § 8º, da CRFB/1988), o que revela a legalidade da hipótese dos autos. Inteligência do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 950569 MS 2016/0183230-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017).

No mais, encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência policial (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 11), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 65/67), bem como pela prova oral coligida.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A testemunha Luciel Carlos de Oliveira, guarda municipal, disse que estavam em patrulhamento quando foram acionados pela central; que a informação era de que o réu estava entregando objetos para outras pessoas, em atitude de mercancia, na praça Cesar Ladeia; que foram até o local; que, com o acusado, nada de ilícito foi encontrado, apenas valor em espécie; que o operador da câmera lhes orientou no sentido de que o réu se dirigia até um arbusto e pegava objetos; que lá constataram a presença de invólucro plástico com entorpecentes; que deram voz de prisão e o conduziram ao plantão; que havia outro rapaz com ele, mas com características diferentes das transmitidas pelo monitoramento; que não se lembrava do réu anteriormente.

A testemunha Cleberson Rodrigo de Jesus disse que o réu foi flagrado pelo sistema de videomonitoramento entregando algo para outras pessoas e escondendo objetos; que foram ao local e abordaram o réu; que encontraram certa quantia de drogas; que as características do indivíduo foram passadas via rádio; que não o conhecia anteriormente; que o acusado assumiu que estava exercendo a traficância há dois dias no local.

A testemunha Saulo Marcelino Correa disse que estava trabalhando no controle de videomonitoramento; que visualizou o réu em atitude suspeita, consistente em pegar dinheiro e entregar objeto para o indivíduo, escondendo invólucro em local próximo posteriormente; que não o tinha visto anteriormente; que não conhecia o acusado;

que acionam a viatura da guarda municipal ao visualizar prática potencialmente delituosa.

Interrogado, o réu Wellington de Oliveira Leite confirmou que, no dia dos fatos, “cometeu o erro”; que foi beber em local próximo; que encontrou outro amigo; que pediu para ele ficar vendendo enquanto ia tomar banho; que aceitou e ficou vendendo as drogas para o indivíduo; que vendeu maconha para duas pessoas; que os guardas chegaram logo na sequência; que tentou ser colaborativo durante a abordagem; que não possuía nenhuma experiência no tráfico; que não estava lá há dois dias.

Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra do acusado se encontra em consonância com o conjunto probatório, em especial com o relato das testemunhas guardas municipais que efetuaram a diligência de apreensão das substâncias.

De proêmio, destaco que o réu foi preso em flagrante, o que, segundo asseverado por José Frederico Marques, consubstancia a “certeza visual do crime” (MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Brookseller, 1997, v. IV, p. 175).

Outrossim, na espécie, colheu-se a confissão espontânea do réu em solo judicial. Sobre a grande importância da confissão judicial, Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Trilhando caminho semelhante há o entendimento da jurisprudência:

“Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: “A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

No mais, não há por que se desconfiar da palavra dos guardas municipais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente transportar e trazer consigo drogas para entrega e consumo de terceiros, o que ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: “A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Ainda que assim não fosse, o próprio acusado admitiu, de forma espontânea, que efetivamente estava comercializando drogas quando abordado e que já havia vendido maconha para duas pessoas, o que restou corroborado pelo vídeo da câmera de segurança da Câmara Municipal exibido em audiência (upload à fl. 124).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico. O fato é típico e ilícito,

e o acusado é culpável.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

Em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assinalo que, quanto à culpabilidade, o réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo; quanto aos antecedentes, o réu é tecnicamente primário e não ostenta antecedentes (fl. 27); os elementos coletados a respeito de sua conduta social e personalidade não se afiguram suficientes para apreciação aprofundada de tais circunstâncias; o motivo e as circunstâncias do crime são as inerentes ao tipo penal e encontram-se relatadas nos autos; as consequências foram as normais para esta espécie; por se tratar de crime contra a saúde pública, nada a considerar acerca do comportamento da vítima. Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, inexistem agravantes a serem consideradas. Reconhece-se a confissão, a qual não tem o condão de alterar a reprimenda, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Por derradeiro, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é tecnicamente primário e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

Anoto que sua condenação definitiva nos Autos nº 1500097-73.2021.8.26.0394, por fato análogo, mas posterior ao ora em apreço, não é suficiente para afastar o benefício supracitado, nos termos de recente entendimento do Col. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTO APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A negativa da a minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC n. 534.671/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/11/2019). III - In casu, o afastamento da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi estabelecido com base na existência de uma condenação transitada em julgado, pelo mesmo crime, por fato ocorrido posteriormente ao delito em apreço, fundamento em desacordo com a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 720431 SC 2022/0023377-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022)

Desta feita, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3, totalizando 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 167 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Ausentes elementos acerca da capacidade financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no piso legal.

Ante a primariedade do réu e por serem as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicial aberto, para o início do cumprimento da pena de reclusão, consoante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Nesse ponto, ressalto recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada, não possui natureza hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida." (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Pelos mesmos motivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 1 salário mínimo vigente, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR o réu Wellington de Oliveira Leite, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, no valor mínimo legal; substituída a primeira por duas penas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.

Considerando que o réu responde o processo em liberdade, concedo-lhe o direito de apelar nesta condição, se por outro motivo não estiver preso.

Custas ex lege.

Determino a destruição da substância entorpecente e o perdimento do valor e dos instrumentos apreendidos, na forma da lei.

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução definitiva.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se. Intimem-se

Nova Odessa, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA